

1500171-28.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... "EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O

tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500171-28.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500171-28.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO JULIANO OLIVEIRA DA SILVA e JOSÉ WEMERSON DA CONCEIÇÃO SILVA

483.902.488-08 e 712.696.974-04

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

JOSÉ WEMERSON DA CONCEIÇÃO SILVA e BRUNO JULIANO OLIVEIRA DA SILVA foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, porque no dia 11.02.2022, por volta das 17h, na Rua Cinco, nº 100, Greenpark, neste município e comarca de Bragança Paulista/SP, traziam consigo, em unidade de desígnios, para fins de consumo de terceiros e fornecimento alheio, 37 papелotes de cocaína, pesando aproximadamente 26g, 12 papелotes de cocaína, pesando aproximadamente 13g, 12 (doze) porções de maconha, pesando aproximadamente 27g e 2 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 390g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente constantes nos autos. Os acusados foram notificados (fls. 177 e 179) e apresentaram defesa preliminar

(fls. 183/184). A denúncia foi recebida em 07.04.2022 e o processo foi saneado (fls. 187/190) .

Em audiência realizada no formato on line, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, em seguida, os acusados foram interrogados. Na ocasião, foi deferido requerimento da Defesa, para juntada de laudo de insanidade mental do acusado Bruno, pertinente a outro feito (fls. 205/206).

Após a juntada da prova pericial (fls. 225/231), foi encerrada a instrução processual, com manifestação das partes através de memoriais (fls. 233).

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 237/245).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição dos réus por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou pela desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da lei de tóxicos. Por fim, teceu comentários acerca da dosimetria da pena, bem como requereu a concessão do tráfico privilegiado (fls. 249/262).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal procede em parte.

A materialidade delitativa vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), pelo auto de constatação provisória (fls. 20/21), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 149/160), assim como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria delitativa também é certa.

O acusado José Wemerson, nas duas vezes em que foi ouvido nos autos, negou a prática delitativa. Na fase policial, disse que estava em um bar, onde almoçava, ocasião em que avistou os guardas municipais abordando um indivíduo desconhecido, qual seja, o ora acusado Bruno. Em seguida, o interrogando também foi abordado pelos agentes públicos. Disse que apenas portava a quantia de R\$154,00, fruto de seu trabalho como servente de pedreiro. Negou ter dispensado os entorpecentes pouco antes da abordagem policial (fls. 12).

Em juízo, José Wemerson alterou parte de sua versão, mas novamente negou a autoria delitativa. Disse que se dirigia ao bar para comprar cigarros, quando viu os guardas municipais abordando um rapaz. Em seguida, os guardas também o abordaram. Na ocasião, eles apresentaram uma sacola, mas não chegou a ver as drogas. Mencionou que apenas tinha dinheiro, no valor de R\$ 154,00, fruto de seu trabalho.

Na fase policial, o acusado Bruno disse que se dirigiu ao bar para comer um pastel e, após ter feito seu pedido, foi abordado pelos guardas municipais. Na revista pessoal, os policiais encontraram, apenas, o valor de R\$410,00, fruto de seu trabalho como vendedor de biscoito. Mencionou que estava sozinho. Por fim, negou ter dispensado drogas no local (fls. 13).

Quando ouvido em juízo, Bruno novamente negou a prática delitativa. Disse que não sabe de nada a respeito das drogas apreendidas no local. Na ocasião da abordagem, estava sozinho e foi detido pelos guardas. Em seguida, eles entraram no bar e abordaram José Wemerson. Por fim, mencionou que é usuário compulsivo de cocaína. Não obstante as versões exculpatórias dos acusados, os depoimentos dos agentes da lei esclareceram como os fatos ocorreram e confirmam, assim, a responsabilidade criminal deles.

O guarda municipal Carlos Henrique da Silva Lima afirmou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizou o momento em que acusado Bruno dispensou um objeto que tinha na mão. O depoente também viu o acusado José Wemerson dispensando um objeto de cor azul, perto de um terreno situado no mesmo local. Em seguida, foi efetuada a abordagem dos acusados. Com Bruno encontraram o valor de R\$ 410,00 em notas trocadas, cuja origem não soube explicar. Na sacola dispensada por Bruno foram encontrados 37 pinos de cocaína e 12 papелotes de cocaína. Com José Wemerson também foi encontrado dinheiro, além de 12 porções de maconha no seu bolso. O objeto azul dispensado por José Wemerson se tratava de tijolo de maconha. Acrescentou que o cão farejador também encontrou no local diversos pedaços de maconha.

O guarda municipal Mauro Pereira Filho informou que já conhecia os acusados, uma vez que eles já tinham fugido em outra abordagem. Na data dos fatos, durante

patrulhamento de rotina pelo local em questão, conhecido ponto de traficância, avistou os acusados em atitude suspeita. O depoente notou que o acusado José Wemerson portando uma sacola com drogas. Os acusados estavam juntos na calçada e foram abordados. O guarda Carlos efetuou a abordagem de Bruno. O cão farejador encontrou mais drogas escondidas no meio do mato.

Consoante se extrai da prova oral acima, há prova segura acerca da responsabilidade penal dos acusados.

Destarte, não obstante as versões destoadas dos indigitados, verifico que os relatos dos agentes públicos foram coesos e firmes quando narraram os fatos, sobretudo acerca da abordagem dos acusados, a dispensa das sacolas por cada um dos acusados e o encontro das drogas em poder deles.

E mais. Os guardas também mencionaram que os acusados estavam juntos na ocasião da abordagem, em local conhecido como ponto de trafico, tendo demonstrado atitude suspeita. Segundo eles, os acusados, ao notarem a aproximação policial, dispensaram as drogas que portavam, na tentativa de se desvencilharem da responsabilização. E tais testemunhas, em razão da função pública que exercem, bem como do compromisso que prestaram em juízo de dizer a verdade, merecem total confiabilidade, não havendo motivos para deles duvidar. Aliás, nada foi apresentado contra os agentes públicos, não havendo indícios mínimos de que estivessem incriminando pessoa inocente.

Justamente em razão de tal situação, muito já se decidiu que: “Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes”.

Ademais, o simples fato de serem policiais não invalida seus depoimentos: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello). E pelo relato dos dois guardas, o fato é que os rapazes estavam juntos no momento da abordagem, em local conhecido como ponto de venda de drogas, em que pese a tentativa dos indigitados de se retirarem da cena do crime.

Ora, por qual motivo os guardas abordariam os rapazes, se eles apenas estivessem dentro do bar para uma refeição, tal qual por eles alegado?

Causa estranheza, neste particular, que nenhuma testemunha presente no bar tenha sido ouvida em juízo, a fim de corroborar a versão dos dois rapazes.

Ademais, não obstante a negativa dos acusados a respeito da propriedade das drogas, observo que os dois guardas civis foram uníssonos quando afirmaram que visualizaram os dois acusados dispensando as drogas que portavam, fato que inclusive motivou a abordagem.

Aliás, o guarda civil Mauro mencionou que já conhecia os acusados de outra abordagem, ou seja, não se trata de um fato isolado.

E a diligência vai além, pois os guardas prosseguiram nas diligências e, com auxílio do cão farejador, eles localizaram mais entorpecentes, que estavam escondidos em local bem próximo a eles.

Da mesma forma, observo que além da droga, os guardas localizaram dinheiro com os dois acusados, em notas trocadas, cuja origem não foi comprovada.

Desse modo, é evidente que os acusados estavam conluiados para a prática do tráfico.

Neste contexto, destaca-se que, mesmo não tendo os policiais presenciado ato de mercancia de entorpecentes, é certo que as circunstâncias do caso indicam o tráfico.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: "O delito de tráfico de entorpecentes possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes, cada uma, por si sós, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão" (TRF, 4ª R., Ap. 2000.70.02.002228-3-PR, 1ª T., j. 11-6-2001, rel. Juiz José Luiz B. Germano da Silva, DJU de 4-7-2001, RT 793/727).

E por este contexto, inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos, conforme arguido pela Defesa.

Destarte, os acusados não comprovaram nos autos a aduzida condição de dependência química, tampouco a assertiva de que as drogas seriam destinadas para uso próprio, ônus que lhes cabiam. Ademais, é sabido que usuários exercem o tráfico de drogas para sustentar o próprio vício.

Por sua vez, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas em poder dos indigitados, conforme constatado pelo laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 149/160), são incompatíveis com a condição de meros usuários.

Ademais, consoante já decidido, "A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do acusado, normalmente, é suficiente para configurar o injusto previsto no art. 12 da Lei de Drogas, somente afastado quando o elemento 'para exclusivo uso próprio' encontra relevante respaldo na prova dos autos. O tipo previsto no art. 12 é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se o tipo subjetivo no dolo." (REsp 347.909/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 05/02/2002, DJ 04/03/2002, p. 290).

Aliás, não obstante a alegação do acusado Bruno, no sentido de que ele é usuário compulsivo de cocaína, observo que o resultado do laudo de avaliação pericial juntado aos autos (fls. 225/231) não corroborou tal assertiva.

Da mesma forma, observo que não se trata de fato isolado em sua vida, considerando-se que está sendo processado em outro feito por fatos análogos (autos nº 1500270-32.2021.8.26.0545 - fls. 56/57).

Assim, considerando a diligência policial com resultado positivo; considerando que o local é conhecido ponto de traficância, considerando o encontro de considerável quantidade e variedade de drogas em poder dos acusados, além de dinheiro em notas trocadas, resta devidamente comprovado o tráfico de drogas.

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo a dosar a pena a ser imposta.

Partindo-se do mínimo legal de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, e não havendo outras circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas nesta primeira fase, a pena-base dos acusados deve ser mantida no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação de pena inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas e que alterem o quantum fixado.

Na terceira fase de aplicação de pena, deixo de considerar o tráfico privilegiado, pelo menos em relação ao acusado Bruno. Referida causa de diminuição de pena tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida.

No caso em tela, embora primário, não se pode ignorar os elementos que indicam que ele vinha se dedicando ao tráfico, uma vez que ele responde por igual delito (autos nº 1500270-32.2021.8.26.0545).

De igual forma, a droga a ele atribuída é de maior potencialidade lesiva, pois ele não apenas dispensou, mas levava consigo papелotes de cocaína. E mais. Em seu poder havia, ainda, a relevante quantia de R\$ 400,00, produto do ilícito.

A diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar aqueles infratores que agiram ocasionalmente, não sendo esta a hipótese dos autos.

Assim, feitas tais considerações, mas atenta ao quantum de pena aplicado, fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Atenta ao quantum de pena, inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

A situação é diferente em relação ao acusado José Wemerson. Não se ignora, neste particular, a razoável quantidade de droga apreendida em seu poder e sob sua responsabilidade, pois a ele foi atribuída a responsabilidade pela maconha.

No entanto, apenas da quantidade da droga não se pode extrair que ele vinha se dedicando a atividade criminosa. Note-se, neste particular, que ele é primário, sem maus antecedentes, não era conhecido dos meios policiais, sendo que sua prisão se deu por acaso, sem que existissem denúncias que o envolviam no tráfico. Assim, forçoso reconhecer o privilégio. Diante da apreensão de relevante quantidade, reduzo a pena de metade e chego a 2 anos 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida”. (HC n.º 118.533, Rel. Cármen Lúcia, j. em 23.06.2016).

Sob essas premissas, cabe ao Julgador analisar a realidade dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

Portanto, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, frente às particularidades acima e com base no art. 33, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para a execução da pena privativa de liberdade.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período da pena privativa, além da limitação de fim de semana, a ser especificada no Juízo da Execução.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar o acusado JOSÉ WEMERSON DA CONCEIÇÃO SILVA ao cumprimento da pena de 02 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto, com conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, com possibilidade de recurso em liberdade; b) condenar o acusado BRUNO JULIANO OLIVEIRA DA SILVA ao cumprimento de uma pena de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de recurso, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Recomende-se o acusado Bruno na prisão em que se encontra e expeça-se alvará de soltura em relação a José..

Comunique-se o teor desta decisão nos autos do Habeas Corpus nº 2029073-17.2022.8.26.0000 (fls. 129/137).

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro, em favor da União (FUNAD), o perdimento da aparelho celular e dos valores apreendidos nos autos, o que faço forte no art. 63 e seu § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

Os acusados ficam isentos do pagamento das custas, uma vez que beneficiários da Justiça Gratuita.

P.I.C.

Bragança Paulista, 07 de dezembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA